

1501752-08.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... de pena relativa ao delito de tráfico e a fixação, quanto aos dois crimes, do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Finalmente, requereu a aplicação do disposto no §2º do artigo 387, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501752-08.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501752-08.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FRANÇA REIS ALBERTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

GABRIEL FRANÇA REIS ALBERTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", deste mesmo diploma legal porque, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 11h43, no campo de futebol situado na Rua 8, nº 8, Vila Margarida, neste município, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 57 porções de cocaína e 11 porções de cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi também apreendida com o réu a quantia de R\$576,50.

Consta, também, que, no período compreendido entre os dias 13 e 14 de maio de 2022, neste município, em ocasião de calamidade pública, o acusado recebeu o aparelho de telefonia celular Samsung, IMEI nº 351763-11-292497-0, que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e ofereceu resposta à acusação. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes ofereceram suas alegações finais escritas. O Ministério Público pediu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Requereu, quanto ao crime de tráfico de drogas, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante na natureza e variedade de drogas apreendidas. Quanto a ambos os delitos, pediu o reconhecimento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, a ser compensada com a circunstância atenuante da menoridade relativa do réu. Pediu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas e, ao final, requereu a fixação do regime inicial semiaberto quanto a este mesmo delito, com o perdimento do valor apreendido.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por ambos os delitos, por falta de provas. Subsidiariamente, quanto aos dois crimes, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública. Pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao delito de tráfico e a fixação, quanto aos dois crimes, do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Finalmente, requereu a aplicação do disposto no §2º do artigo 387, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelas fotografias de fls. 18/19, pelo laudo de exame químico-toxicológico, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática dos crimes descritos na denúncia. Disse que, naquela mesma data, havia comprado um telefone celular para sua irmã, na "feira do rolo", pagando por ele sua bicicleta e um valor em dinheiro, tendo o vendedor lhe dito que o aparelho não era produto ilícito. Contou que retornou para o bairro Vila Margarida e parou no campo do futebol, onde encontrou três ou quatro conhecidos seus, além de Alan. Disse que estes indivíduos estavam fumando "baseado" e permaneceu no local fazendo uso com eles. Contou que permaneceu sentado onde estava quando os policiais chegaram ao local e, então, foi abordado. Alegou que os policiais acionaram apoio e, então, outra viatura policial chegou ao local, momento em que as drogas foram apresentadas. Contou que não viu onde estava as drogas apreendidas. Disse que os policiais liberaram três dos indivíduos abordados e o conduziram juntamente com Alan para a delegacia, sendo Alan também liberado em solo policial. Contou que Alan já estava no local quando lá chegou e permaneceu fumando "baseado" com ele e os demais indivíduos por cerca de 30 a 40 minutos antes da chegada dos policiais. Disse que estava com seu celular em seu bolso e, no momento da abordagem, o outro celular que havia comprado naquela data estava no banco, pois não tinha bolso para colocá-lo. Alegou, então, que o seu celular estava em sua cintura e o outro aparelho estava no banco. Contou que estava ao lado de Alan quando foram abordados, mas não soube se Alan viu os policiais pegando o referido aparelho celular. Não conhecia os policiais que o abordaram e não soube se eles tinham algum motivo para prejudicá-lo.

Entretanto, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se a realização do tráfico de drogas por ele, além do delito de receptação. Além disso, sua versão apresentada em Juízo, além de não ser crível, não encontra respaldo no restante das provas produzidas durante o processo.

A vítima do delito de receptação, ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que, no dia 13 de maio, estava dentro de seu veículo quando três indivíduos a abordaram e a sequestraram com a finalidade de roubá-la. Disse que foi conduzida até um local onde um quarto meliante aproximou-se com uma máquina de cartão e, então, os roubadores realizaram transferências de sua conta via pix, bem como compras nos seus cartões de débito e de crédito, além de subtraírem seu aparelho

celular. Declarou que, no dia 14 seguinte, sua esposa recebeu ligação de um policial pedindo que fosse à delegacia para reaver seu aparelho, pois ele havia sido localizado com um indivíduo nesta cidade de São Vicente. Relatou que, na delegacia, foram-lhe mostradas várias fotografias, dentre elas a do indivíduo com quem seu celular foi encontrado, mas não reconheceu nenhuma das pessoas retratadas como sendo as autoras do crime de roubo que sofreu. Consignou que não viu, pessoalmente, o indivíduo com quem seu telefone foi apreendido e esclareceu que, posteriormente, realizou o reconhecimento de um indivíduo envolvido no crime de roubo.

A testemunha policial militar Jefferson Rodrigues de Lima, ouvida em Juízo, relatou que realizava patrulhamento pelo bairro "México 70" e, na rua 8, onde há um campo, em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, viu o acusado com outro indivíduo e viu que ambos, ao notarem a presença policial, assustaram-se e dirigiram-se a um banco, onde sentaram. Narrou que desembarcou juntamente com seu parceiro policial e, ao entrarem no campo, dada ordem para que o réu e o outro indivíduo levantassem, o acusado o fez e dispensou uma sacola para trás do banco. Disse que, em busca pessoal, no bolso do réu foram localizados dois aparelhos de telefone, um dos quais verificou-se ser produto de roubo ocorrido no dia 13, na cidade de Praia Grande. Relatou que, na sacola recuperada, foram encontradas porções de cocaína e de maconha, em quantidade que não recordou. Narrou que, embora o réu tenha sido visto dispensando a sacola para trás do banco e tenha sido o celular encontrado em seu bolso, o acusado declarou nada ser dele. Disse não recordar se também foi localizada quantia em dinheiro. Declarou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Relatou que, com o outro indivíduo abordado, nada de ilícito foi apreendido e este alegou que estava passando pelo local, viu o réu e parou para conversar. Consignou que, após a abordagem e a constatação de que havia drogas na sacola e de que o celular era produto de roubo, populares aglomeraram-se em volta do campo e foi solicitado apoio. Afirmou que o acusado e o outro indivíduo abordado estavam juntos e esclareceu que havia dois ou três indivíduos próximos. Esclareceu que estes foram chamados para serem abordados, mas, constatado que não estavam juntos ao réu e ao outro indivíduo e constatado também que eram menores e que estavam mesmo jogando bola, foram eles liberados.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar Luiz Fernando Nóbrega Lopes, ouvida em Juízo, narrou que realizava patrulhamento quando avistou dois indivíduos, um deles o acusado, que tinha um volume na cintura. Declarou que ambos demonstraram nervosismo e correram e os viu sentarem em um banco situado em um campo de futebol, vendo, também, o acusado jogar uma sacola plástica para baixo desse banco. Relatou que, na sacola, foram localizadas maconha e cocaína, e, com o acusado, foram encontrados dois aparelhos de telefone, um deles produto de roubo na cidade de Praia Grande, em data anterior aos fatos. Disse que o indivíduo que estava com o acusado também foi conduzido à delegacia, para ser averiguada sua relação com os fatos. Asseverou que o acusado e o outro indivíduo abordado sentaram-se sozinhos no banco atrás do qual o réu dispensou a sacola. Esclareceu que viu outras pessoas nas imediações, mas não no banco onde o acusado estava, e tais pessoas não foram relacionadas no BOPM, tendo sido somente o réu e o outro indivíduo conduzidos à delegacia. Não recordou se o réu forneceu esclarecimentos sobre as drogas e o celular apreendidos. Consignou que o aparelho celular apreendido foi encontrado no bolso do réu. Não recordou se também foi apreendido dinheiro com o acusado. Declarou que o local dos fatos, onde o réu foi detido, é conhecido pela ocorrência intensa do tráfico de drogas, e não conhecia o réu anteriormente aos fatos.

A testemunha de defesa Alan Adriano dos Santos Bezerra, ouvida em Juízo, disse conhecer o réu de vista há alguns anos das "quebradas", do bairro Vila Margarida, onde moram. Contou que havia cinco ou seis pessoas no local onde o acusado foi preso. Disse que já estavam sentados no banco e ali permaneceram quando uma viatura policial aproximou-se e os policiais os abordaram e revistaram todos. Contou que os policiais fizeram busca no local e nada encontraram, sendo que outra viatura foi chamada e policiais que nela estavam fizeram busca pelo campo, momento em que uma sacola com droga foi apresentada. Disse que não viu se um celular foi apreendido na posse do acusado, alegando que não teve tempo de ver se o acusado estava com

aparelho, pois havia chegado ao local pouco antes de os policiais se aproximarem. Contou que também não viu se o réu jogou alguma sacola no local. Disse que todas as pessoas abordadas estavam próximas.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas e à receptação, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra das testemunhas policiais, que, de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes de que forma ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da droga.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Min. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provisamento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino - Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva - Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais militares não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos destas testemunhas, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização do entorpecente e do aparelho celular produto de roubo em data anterior, estando em harmonia com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

As contradições alegadas pela Defesa não se encontram presentes.

Ao contrário, observa-se que as testemunhas, em Juízo, puderam fornecer relatos com maior riqueza de detalhes e ambas, pormenorizadamente, narraram onde viram o acusado, acompanhado de somente um indivíduo, esclareceram qual a conduta de ambos ao notarem a presença da equipe policial, afirmaram que somente eles dois sentaram-se no banco, asseveraram que viram o réu dispensar uma sacola que, recuperada, verificaram conter drogas, e, finalmente, que encontraram, no bolso do acusado, o aparelho celular que constatarem ser produto de crime.

Ainda ao revés do aduzido pela Defesa, em nenhum momento de suas declarações a testemunha policial Jefferson relatou terem sido abordados o acusado e mais quatro indivíduos.

Disse o policial Jefferson que o réu e o outro indivíduo visto inicialmente com ele estavam juntos e consignou que duas a três pessoas estavam próximas, foram chamadas para perto para serem abordadas, mas foi constatado que elas não possuíam relação com os fatos e foram liberadas.

Nessa mesma toada, saliente-se que a testemunha Luiz Fernando afirmou que havia outros indivíduos nas imediações, mas nenhum outro, além do réu e daquele homem que desde o início foi visto com ele, foi conduzido à delegacia ou relacionado no BOPM. Veja-se, ainda, que a testemunha Jefferson bem esclareceu que realizava o patrulhamento pela Rua Oito, onde há o campo, quando avistou o acusado com o outro indivíduo e que os viu dirigirem-se ao banco ao notarem a presença da equipe policial, ali sentando-se, tendo visto o réu dispensar a sacola.

Esta mesma narrativa foi apresentada pela testemunha policial Luiz Fernando, que viu o acusado e o outro indivíduo dirigirem-se ao banco assim que viram a viatura policial, sendo que o réu dispensou a sacola, confirmando, ambas as testemunhas, a mesma dinâmica descrita na exordial acusatória.

Não há dúvidas, portanto, que o acusado estava portando o aparelho celular produto de ilícito e que a ele pertenciam as drogas contidas na sacola por ele dispensada momentos antes da abordagem.

De outro lado, as declarações da testemunha arrolada pela Defesa não abalou em nada os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Observe-se que a dinâmica descrita por Alan sequer coincide com aquela oferecida pelo acusado em seu interrogatório.

Note-se que Alan chegou a salientar, ao ser questionado sobre ter visto a apreensão do aparelho telefônico com o réu, que havia chegado ao local onde estaria o réu e outros indivíduos momentos antes dos policiais os abordarem e que sequer teve tempo de ver se o acusado estava com celular.

Já o acusado alegou que Alan e demais indivíduos já estavam no local da abordagem fumando "baseado" e que se juntou a eles, permanecendo no local por 30 a 40 minutos até que os policiais chegaram e os abordaram.

Dessa forma, a versão apresentada pelo acusado restou isolada do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo réu sobreponha-se ao depoimento dos policiais encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem os delitos.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos, bem como as diligências realizadas no curso da ação penal, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasar a inequívoca conclusão de que o réu é, de fato.

Consigne-se que não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

As graves acusações feitas contra os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório.

Argumentos genéricos que visam a desprestigiar a Polícia como um todo em nada influenciam na prova colhida no presente caso.

Assim, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu deriva da natureza, da variedade e da quantidade de entorpecente e demais circunstâncias em que a droga e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310). Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a variedade e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, é medida que se impõe.

Outrossim, a materialidade e a autoria do crime de receptação, repise-se, restaram bem demonstradas.

Pelas declarações das testemunhas policiais militares, da vítima e pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, não há dúvidas acerca da prática do crime de receptação pelo acusado, porquanto foi ele detido na posse do aparelho celular subtraído na data anterior aos fatos.

Tratava-se, portanto, de produto de crime.

Para a configuração do crime de receptação dolosa, faz-se mister, também, haver prova de ter o agente atuado com dolo direto, ou seja, com a certeza quanto à proveniência ilícita da coisa.

Como é cediço, perscrutar a intenção do réu em casos que tais é praticamente impossível, porquanto o conhecimento sobre a origem da coisa está inserto numa fase intelectual, tornando difícil a produção desta prova.

Diante disso, admite-se tal comprovação, levando-se em consideração a conduta do agente, os indícios e circunstâncias que envolveram a infração e a inexistência de justificativa plausível de estar portando o celular subtraído da vítima em ação criminosa diversa no dia anterior àquele em que houve a abordagem, o que dá causa à inversão do ônus da prova.

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples, podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração” (RT 726/666).

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação”. (TACRSP - RT 746/629)

Assim, com base nas declarações da vítima e das testemunhas policiais e demais elementos de convicção, o dolo do réu revela-se patente. Não apresentou justificativa plausível a respeito dos fatos. Nada apresentou que demonstrasse a aquisição do aparelho celular em uma transação lícita. Ao contrário, disse tê-lo comprado na “feira do rolo”, de um indivíduo não identificado, que lhe teria dito não ser o telefone produto de roubo.

Certamente, à luz destas circunstâncias, ninguém se animaria em asseverar que o réu não sabia sobre a origem ilícita da coisa.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, justifica-se o aumento da pena em 1/6. Assim, fixo sua pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no

Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Reconhecida, outrossim, a circunstância atenuante da menoridade relativa, ficam estas circunstâncias compensadas. Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida. Contudo, forçoso reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é primário e não há elementos nos autos que possam indicar que o réu se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Contudo, considerando a quantidade de drogas apreendidas, a diminuição se dará em 1/2, ficando a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal.

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Quanto ao delito de receptação, atentando-me para os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em 1 (um) de reclusão e 10 dias-multa, no patamar mínimo.

Na segunda fase da aplicação da pena, na forma como já exposto, reconhecidas as circunstâncias agravantes e atenuantes da calamidade pública e da menoridade relativas, ficam elas compensadas, motivo pelo qual a pena fica inalterada nesta fase.

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, devem as penas ser somadas, o que resulta na pena final de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, no valor mínimo legal. Verifica-se, portanto, fixação de pena em patamar inferior a quatro anos o que, atualmente, preenchidos os demais requisitos legais, enseja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A expressa vedação quanto à substituição de pena constante do artigo 44 da lei 11.343/06 foi suspensa pela Resolução nº 5/2012 do Senado Federal.

Em caso de descumprimento o regime inicial de pena privativa de liberdade será o regime aberto.

Passo, portanto, a análise dos requisitos legais. Estando presentes os requisitos previstos nos incisos I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis) do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade, que deverá ser cumprida a razão de uma hora para cada dia de condenação, em local a ser fixado pelo juiz da execução, e também pela pena de outros 10 (dez) dias-multa, no mesmo valor já estipulado.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GABRIEL FRANÇA REIS ALBERTO, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em concurso material, ficando a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no valor equivalente a 10 dias-multa, como acima especificado.

Diante do montante de pena privativa de liberdade imposta e a substituição aplicada, não mais se justifica a manutenção da prisão cautelar do acusado, motivo pelo qual lhe concedo o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 27 de setembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA